

Tema 1234 e Tema 6 do STF: Desafios para judicialização da saúde no âmbito do SUS

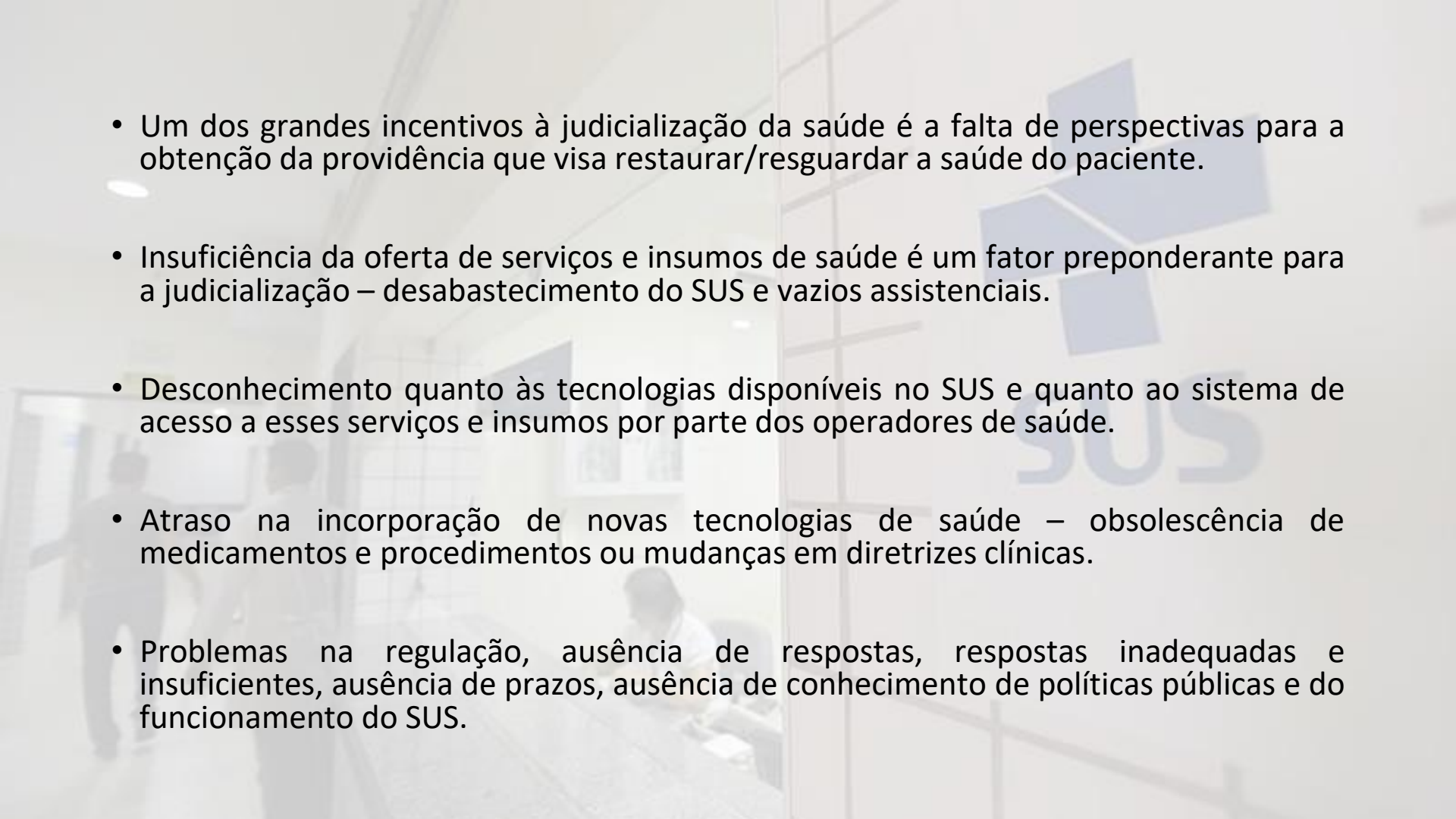
Eni Maria Sezerino Diniz – Defensora Pública
Coordenadora do Núcleo de Atenção à Saúde
(NAS)
Dezembro de 2024



- **A judicialização da saúde e seus motivadores:**

- Conceito que define não a quantidade das ações mas sim um problema de política pública coletivo que é posto ao Judiciário de forma individual. É multifatorial e multifacetada.
- É hoje a medida mais frequente para a tentativa de obtenção da providência de saúde, no entanto não é a mais rápida e nem a mais efetiva. Segundo DATAJUS do CNJ demora em média 432 dias até o julgamento da ação.
- Estabelecimento de **prazos** pelo CNJ (Enunciados FONAJUS), e de **critérios** pelo STF e STJ (Temas Repetitivos) para a judicialização de providências de saúde.
- Judicialização sem o conhecimento prévio dos motivos efetivos da não disponibilização da providência de saúde solicitada já não é mais admitida.



- 
- Um dos grandes incentivos à judicialização da saúde é a falta de perspectivas para a obtenção da providência que visa restaurar/resguardar a saúde do paciente.
 - Insuficiência da oferta de serviços e insumos de saúde é um fator preponderante para a judicialização – desabastecimento do SUS e vazios assistenciais.
 - Desconhecimento quanto às tecnologias disponíveis no SUS e quanto ao sistema de acesso a esses serviços e insumos por parte dos operadores de saúde.
 - Atraso na incorporação de novas tecnologias de saúde – obsolescência de medicamentos e procedimentos ou mudanças em diretrizes clínicas.
 - Problemas na regulação, ausência de respostas, respostas inadequadas e insuficientes, ausência de prazos, ausência de conhecimento de políticas públicas e do funcionamento do SUS.

- Dificuldades de composição extrajudicial com o Poder Público – indisponibilidade do interesse público.
- SUS – Políticas Públicas em constante construção e expansão. Mudança de gestores do SUS.
- Não existem apenas dois polos, mas uma série de entes que devem atuar na efetivação do direito à saúde – pactuações intergestores e com prestadores de serviços impactam na oferta e disponibilização do serviço.
- Combater a ideia de ‘fura fila’ das demandas da DP – não há uma fila da regulação (onde cada um teria o seu número) mas sim uma LISTA DE ESPERA que muda a cada momento dependendo da evolução do quadro do paciente ou da inserção de novas solicitações – a DP apresenta demanda qualificada com a atual condição do paciente.



Tema 1234 do STF:

O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 136643, fixando a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema nº 1.234), para fins de fixação de competência:

- a) As demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, com registro na ANVISA, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. Nesses casos, os medicamentos serão custeados integralmente pela União.
- b) Consideram-se medicamentos não incorporados: - aqueles que não constam na política pública do SUS; - medicamentos previstos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDTs) para outras finalidades; - medicamentos sem registro na ANVISA; e - medicamentos off label, sem protocolo clínico ou que não integrem listas do componente básico.
- c) Tratando-se de medicamento não incorporado, é da parte autora o ônus de demonstrar a segurança e a eficácia do fármaco, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências (prova da existência de ensaios clínicos randomizados), bem assim a inexistência de substituto terapêutico padronizado no SUS.

- d) Quando o custo anual unitário do medicamento ficar entre 7 (sete) e 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a competência será da Justiça Estadual. A União deverá ressarcir 65% das despesas decorrentes de condenações dos estados e dos municípios.
- e) Medicamentos oncológicos não incorporados terão um percentual de ressarcimento de 80% pela União, em ações ajuizadas até 10.06.2024, se o custo for superior a 7 (sete) salários-mínimos.
- f) Fica mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União (Tema 500).
- g) As demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS, com pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), os Entes concordaram em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. Caberá ao magistrado determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao acórdão. Desse modo, fica mantida a competência da Justiça Federal, cuja a responsabilidade pela aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde (Grupo 1ª e Componente Estratégico).

- O Judiciário NÃO pode aplicar por analogia o Tema 1.234 a materiais, órteses, internações. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
- Durante um ano, em caso de declinação da Justiça Estadual para a Federal (novos casos) e na hipótese de incorrer atendimento pela DPU (por inexistência do serviço ou critério de renda) admite-se a atuação da DPE que tenha promovido o ajuizamento da ação no foro estadual.
- Sequestro de verbas e ordens de depósito – Tema 1234 do STF: Consta na decisão do tema que na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (...), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

- EMENTA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE APLICAR A TABELA DE PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG) - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA FEITA DIRETAMENTE PELO PARTICULAR EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
- A Tabela de Preço Máxima de Venda ao Governo somente deve ser observada quando a venda dos medicamentos for direcionada aos entes públicos e não quando a compra é feita por particular. (25/11/2024 TJMS 1ª Câmara Cível). (...) No caso, verifico que a aquisição não será realizada por qualquer ente da administração pública direta ou indireta, mas pela própria autora, ora agravada, razão pela qual não há que se falar em aplicação do Tema 1234.

Tema 6 do STF - Requisitos para acesso a medicamentos não incorporados e de alto custo:

1º requisito:

- Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa.

2º requisito:

- Ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011.

3º requisito:

- Impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

4º requisito:

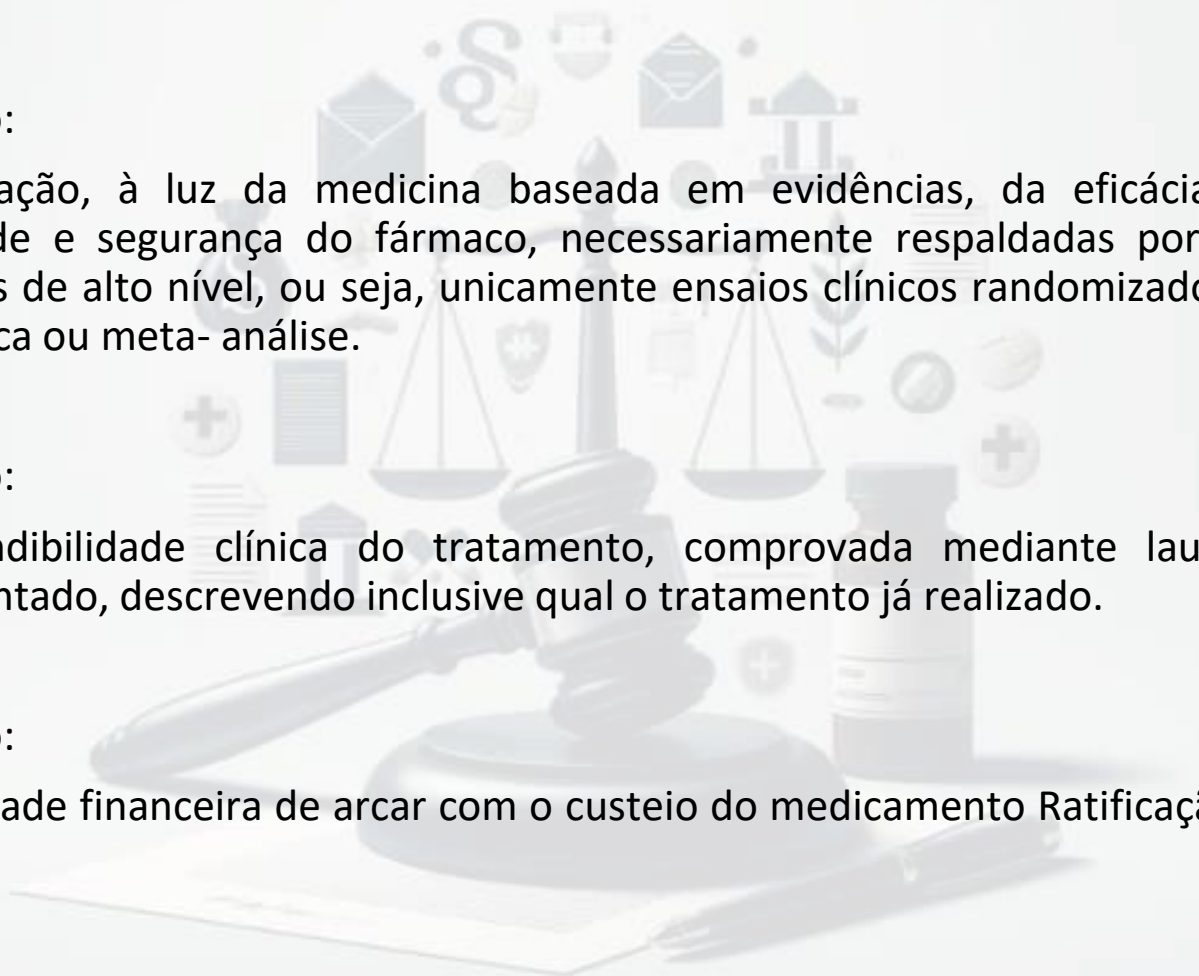
- Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta- análise.

5º requisito:

- Imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado.

6º requisito:

- Incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento Ratificação do Tema 6 do STJ



Considerações finais:

- Atenção integral implica em cuidado não fragmentado – atuação extrajudicial envolve conhecimento da estrutura do SUS e persistência na articulação com os gestores a fim de superar os entraves que se apresentam com os Temas 1234 e 6 do STF.
- Com a articulação extrajudicial há a possibilidade de efetivar as políticas públicas de saúde já existentes e reconhecidas como direito dos assistidos, e de fomentar novas políticas, bem como a devida inserção dos usuários nas políticas públicas disponíveis.
- O diálogo interinstitucional é imprescindível para a construção de fluxos de atendimento que sejam adequados à realidade de cada localidade.
- Fomento à noção de racionalização da judicialização em detrimento do conceito de ‘desjudicialização da saúde’ – judicializar-se a providência não atendida pelo SUS, seja pela inexistência de alternativa terapêutica adequada ou pela exiguidade de oferta dos serviços que devem ser disponibilizados.